

1500187-93.2020.8.26.0660

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Comarca: Viradouro

Foro: Foro de Viradouro

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL E SEM ELEMENTOS MÍNIMOS DE TRAFICÂNCIA NO LOCAL. PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. Ainda que esta Sexta Turma tenha admitido como fundamento para a prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Viradouro

Foro de Viradouro

Vara Única

Rua José Borelli, 10, Viradouro - SP - cep 14740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Sentença nos autos sob o n. 1500187-93.2020.8.26.0660 - lauda de
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500187-93.2020.8.26.0660

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREY LUIZ CASSIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Vistos e examinados os presentes autos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia ANDREY LUIZ CASSIANO, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que, no dia 13 de maio de 2020, por volta das 23h30, na Rua Luzia Camargo Garcia, Centro, nesta cidade e Comarca, ele mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, aproximadamente 109,27 gramas de maconha, divididos em três porções, uma delas na forma de um tijolo, mais 53 microtubos plásticos utilizados para embalar entorpecente para venda, tratando-se de droga que causa dependência física e psíquica, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O acusado foi preso em flagrante (f. 01/05) e lhe foi concedida a liberdade

provisória, conforme decisão de f. 49/52.

O acusado foi notificado (f. 133) e apresentou defesa preliminar (f. 140/142).

A denúncia foi recebida no dia 19 de novembro de 2020 pela decisão de f. 143/145 e o réu foi citado (fl. 176).

Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas e, por fim, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência parcial da denúncia, com desclassificação da imputação para o delito do art. 28d a Lei n. 11343/06, com aplicação da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado, reiterando a resposta à acusação.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. .

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha RONALDO ADRIANO LOPES, policial militar, ouvido na fase de inquérito (f. 02), afirmou: “Em patrulhamento, na companhia do PM Williams, na data dos fatos, quando recebemos denúncia anônima dando conta de que um rapaz de nome Andrey estaria utilizando sua residência como ponto de tráfico de drogas, na Rua Luiza Camargo Garcia, n. 13, nesta, então rumamos até o referido endereço e, ao nos aproximarmos do local, vimos um rapaz defronte à calçada, no endereço indicado, guardando uma bicicleta, com a aproximação da viatura, o indiciado tentou se evadir, correndo para dentro de casa, tendo sido abordado pelo CB Williams, em busca pessoal, no quintal da casa, nas vestes do indiciado nada de ilícito foi encontrado, a gente deu ciência para o indiciado a respeito das denúncias sobre ele e o local, mas o indiciado Andrey negou a traficância, ainda nos disse que dentro da casa onde foi abordado e residia, havia apenas maconha para consumo pessoal, franqueando-nos a entrada, levando-nos até a sala, em um rack, onde havia um tigel contendo farelos de maconha, bem como uma porção pequena da mesma substância embalada em invólucro transparente, além da quantia de dezoito reais, tratando-se de uma nota de dez, uma nota de cinco, uma nota de dois e uma moeda de um real. Ainda em vistoria, no quarto, embaixo da cama, encontrei um saquinho contendo cinquenta e três pinos vazios, usualmente empregado para embalar cocaína, além de uma porção de maconha em invólucro plástico transparente, tipo tijolo, de maconha, mesmo assim o indiciado Andrey continuou dizendo que a droga seria para consumo pessoal. O indiciado recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado para esta Delegacia de Polícia”.

Em juízo, disse que faziam patrulhamento e tinha informações de populares no sentido de que havia movimento intenso de pessoas na casa; isso ocorria durante a madrugada; seriam usuários de drogas; intensificaram patrulhamento; no dia dos fatos, viraram na rua de forma repentina; o acusado estava empurrando uma bicicleta para entrar no imóvel; ele tentou entrar rapidamente dentro da casa; contiveram o acusado; nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal; indagado sobre as denúncias, ele disse que era usuário e sua casa era frequentada por usuários; ele disse que havia droga no imóvel; franqueou a entrada ao imóvel; na sala, havia um prato com porções de maconha; a casa é pequena; o depoente olhou embaixo da cama e observou microtubos vazios; havia ali uma porção um pouco maior de maconha; conduziram o acusado à Delegacia de Polícia; não se recorda de petrechos para preparo de drogas; as informações sobre o tráfico eram mais recentes; não voltou a abordar o acusado.

A testemunha WILLIAMS JOAO ALVES PRIMO, policial militar, ouvido na fase investigativa (f. 03), relatou: “Em policiamento ostensivo motorizado, na companhia do PM Adriano, na data dos fatos, recebemos denúncia anônima sobre um rapaz de nome

Andrey que estaria usando sua residência como ponto de tráfico de drogas, na Rua: Luíza Camargo Garcia, n. 13, nesta, então nos dirigimos até o endereço indicado na denúncia e ao nos aproximarmos do local, visualizamos um rapaz defronte à calçada, no endereço indicado, guardando uma bicicleta, com a aproximação da viatura, o indiciado Andrey tentou se evadir, correndo para dentro de casa, tendo sido abordado por mim, em busca pessoal, no quintal da casa, nas vestes do indiciado nada de ilícito encontrei, demos ciência para o indiciado a respeito das denúncias em seu desfavor, mas o indiciado Andrey negou a traficância, ainda nos disse que dentro da casa havia apenas maconha para consumo pessoal, autorizando nossa entrada, levando-nos até a sala, em uma mesa de sala, ali havia um tigela contendo farelos de maconha, bem como uma porção pequena da mesma substância embalada em invólucro plástico transparente, além da quantia de dezoito reais, sendo de uma nota dez, uma nota de cinco, uma nota de dois e uma moeda de um real. Ainda em vistoria, no quarto, embaixo da cama, o PM Adriano encontrou um saquinho contendo cinquenta e três pinos vazios, usualmente empregados para embalar cocaína, além de uma porção de maconha em invólucro plástico transparente, tipo tijolo, mesmo assim o indiciado Andrey continuou dizendo que a droga seria para consumo pessoal. O indiciado recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado para esta Delegacia de Polícia”.

Em juízo, disse que, na época, havia denúncias formais e anônimas que o acusado vinha utilizando a sua casa como ponto de tráfico; “nesse dia aí resolvemos checar, averiguar essas denúncias aí”; ao virar na esquina, viram o acusado na calçada empurrando sua bicicleta e ele saiu correndo tentando entrar na sua casa, chamando a atenção dos policiais; abordado, não foi encontrado nada de ilícito em revista pessoal; ele disse que havia droga em sua casa para o próprio consumo; franqueou a entrada na casa; sobre a mesa, tinha tigela com maconha; havia maconha embalada e R\$ 18 em dinheiro; no quarto dele, seu parceiro localizou, embaixo da cama, três pinos eppendorfs; o acusado negou que estava traficando e disse que a droga localizada era para consumo próprio; ele foi levado para a Delegacia de Polícia; abordou o acusado em outras ocasiões; ocasiões anteriores e posteriores; em outras oportunidades, não encontrou nada de ilícito com ele; não se recorda se haveria indícios de que o acusado teria cocaína na casa; os pinos estavam vazios; foram formuladas denúncias contra o acusado através do “190”.

O acusado, ouvido perante a autoridade policial (f. 04), respondeu: “Eu estava dormindo em casa, acordei e lembrei que minha bicicleta estava do lado de fora de casa, saí até calçada, peguei a bicicleta e guardei no corredor de casa, escutei alguém abrindo o portão de casa que não fica trancado, em seguida vi uma luz de lanterna no teto de casa, aí constatei que era o senhor Adriano, este me rendeu, perguntando junto com outro policial se havia alguma coisa em casa, contei que tinha maconha para consumo meu debaixo da cama, o PM Adriano foi lá e pegou, também havia uma tigela com farelos de maconha. Havia pinos vazios em casa, que eu usei, pois também cheiro cocaína. O dinheiro só havia dezoito reais, resultado do meu trabalho na roça. Não sou traficante, comprei a droga de um desconhecido em Ribeirão. Em Ribeirão a droga é mais em conta, quando vou para lá comprou em maior quantidade para o meu uso”.

Em juízo, disse ser usuário de maconha; trabalhava em Ribeirão e dormia na cidade durante a semana; nessa semana, não tinha ido, porque estava mexendo com documentos; estava dormindo quando sua casa foi invadida; a maconha era do seu uso; os pinos eram resultantes também do uso; estava em depressão porque sua mãe tinha falecido e perdeu o emprego; perdeu 35 quilogramas em menos de dois meses; entende que sua casa foi invadida; nunca vendeu drogas e sempre trabalhou. Pois bem.

Após revisar detidamente a prova dos autos, verifico que não há como sustentar a condenação em provas válidas. Entendo que a apreensão das drogas na residência do acusado foi ilícita e, por esta razão, não pode servir à condenação, o que conduz à improcedência da imputação por ausência de substrato probatório. Explico.

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,

ou, durante o dia, por determinação judicial". Conclui-se, pois, que o ingresso na residência só é possível em caso de flagrante delito, por determinação judicial ou com o consentimento válido do morador. Contudo, nenhuma das hipóteses estava presente no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, julgando o HC n. 598.051/SP, definiu as exigências, em termos de standard probatório (standards de prova "são critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado" - BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. São Paulo: RT, 2019, p. 236), para o ingresso policial em domicílio de pessoa suspeita sem mandado judicial, ou seja, para a devida proteção à garantia da inviolabilidade de domicílio, são necessárias providências mínimas.

Para o ingresso na residência em hipótese de flagrante delito, é necessária a existência de fundadas razões (justa causa) aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

A Corte Federal definiu que o tráfico ilícito de entorpecentes, embora seja classificado como crime permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontram as drogas. A entrada somente será permitida em situações de urgências, quando for possível concluir de modo objetivo e concreto que o atraso decorrente da obtenção do mandado judicial possa permitir a destruição ou ocultação da prova do crime ou da própria droga.

Para o ingresso na residência mediante consentimento do morador, é necessário que a autorização seja assinada pelo morador e por testemunhas que atestem que o morador consentiu com o ingresso e que acompanhem a busca realizada, o que deverá ser registrado em auto circunstanciado, em estrita observância ao que determina o art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal, que se aplica a qualquer forma de busca e apreensão domiciliar, com ou sem mandado judicial; ou a diligência deverá ser integralmente registrada em vídeo e áudio, sem cortes ou edição, especialmente se não for possível a assinatura da autorização escrita.

O consentimento para entrada na residência pelo morador deve ser voluntário e livre de qualquer constrangimento ou coação. Vale ressaltar que, havendo dúvida, a prova da existência e validade do consentimento é ônus da prova que recai sobre o Estado, personificado no processo pelo Ministério Público. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo" (HC n. 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021).

Passando à análise do caso concreto, a ausência de autorização judicial é incontroversa, eis que o competente mandado de busca e apreensão em momento algum foi solicitado.

Também não ficou demonstrado que houve consentimento externado pelo morador.

Segundo os policiais militares condutores, o acusado teria sido abordado na rua de sua casa e, com ele, nada de ilícito foi encontrado, contudo, ele teria indicado espontaneamente que possuiria drogas no interior da sua residência.

Formalmente ouvido, em Delegacia de Polícia e em Juízo, o acusado negou que os fatos tenham se passado dessa maneira, bem como negou que tenha dado autorização para o ingresso policial na residência.

Assim, o suposto consentimento do(s) morador(es) para entrada na residência não foi confirmado de qualquer modo, em Juízo ou fora dele. Julgo crível a história do acusado no sentido de que não conferiu tal autorização, até mesmo porque seria absolutamente inusitado que alguém sabedor que guarda drogas em sua residência convidasse policiais militares para uma revista domiciliar.

Ainda que haja elemento de prova em sentido contrário - neste sentido está o depoimento dos policiais militares - não estão presentes elementos suficientes para convencer o Juízo da validade do consentimento. Sobre o tema, ensinam os processualistas PIERPAOLO CRUZ BOTTINI e ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO:

Em muitos casos, policiais adentram residências particulares, sem que presentes quaisquer destas situações excepcionais, sob o pretexto de terem obtido o consentimento do morador. (...) Importante analisar a situação do dito 'consentimento' do morador, apto a excepcionar a regra da inviolabilidade do domicílio e autorizar a busca sem mandado judicial. Sabe-se que, nas buscas domiciliares, há um conflito de interesses em jogo – a busca da verdade, para realização da justiça criminal, e a preservação da intimidade e da inviolabilidade do domicílio. O consentimento do morador aparece como primeira forma de solução desse conflito. No entanto, é preciso cautela na sua análise, sempre diante das circunstâncias de obtenção da prova e da atuação da autoridade policial. (...) O consentimento, porém, deve ser real e livre, despido de vícios como o erro, violência ou intimidação. Evidentemente que, em cada caso concreto, o consentimento do morador deve ser analisado com cautela e nunca presumido, especialmente para que se evitem abusos da autoridade policial. (...) O TJRS recentemente destacou a invalidade do consentimento de pessoa investigada por tráfico de drogas. Na ocasião, o Desembargador relator pontuou: 'Não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o art. 5.º, XI, da CF não se infere que poderão ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do morador. Se assim fosse, veríamos-nos diante de um quadro temerário, no qual os mandados de busca e apreensão seriam dispensáveis, já que polícia sempre poderia conseguir, extrajudicialmente, o 'consentimento' do proprietário. Afinal, é de se ter em conta que, nas circunstâncias descritas nos autos esse aval foi dado sob constrangimento' (Ap 70058172628, Rel. Des. Diógenes V. Hassan Ribeiro, 3.ª Câmara Criminal, DJ 24.06.2014). Dessarte, se há o consentimento do morador para buscas domiciliares, algumas questões devem ser bem refletidas: (I) forma do consentimento; (II) pessoa que consente e seu grau de esclarecimento sobre as implicações da medida. Sobre a forma do consentimento, deve ser expresso e jamais presumido, sendo que não há previsão legal de forma especial. (...). No tocante à pessoa que consente, deve ser aquele titular do direito à inviolabilidade do domicílio. A doutrina destaca que a permissão deve ser do próprio sujeito da medida de busca e apreensão ou de outra pessoa que possa, legitimamente, representá-lo. Ressalvas são feitas, ainda, às habitações coletivas, em que o consentimento por um dos moradores não autoriza a busca na casa ou aposento de terceiros. No entanto, maior relevo tem a questão do grau de esclarecimento do morador que consentiu na realização da busca e apreensão. Para que se solucione o conflito de interesses – busca da verdade para realização da justiça e inviolabilidade do domicílio – por via consensual, é necessário que aquele que consente tenha pleno conhecimento das circunstâncias e consequências da realização da busca domiciliar, bem como que isso seja documentado. No ponto, não há previsão legal. Contudo, tratando-se de medida que pode implicar a produção de prova contra o próprio morador que consente com a busca, para que ele decida de forma justa e válida se franqueará a entrada em sua residência, necessário que no mínimo lhe sejam esclarecidos seus direitos e o alcance da inviolabilidade do domicílio, bem como as consequências da realização da busca domiciliar. A mesma lógica e o mesmo cuidado são observados nos procedimentos de interrogatórios, tanto judicial quanto policial, a fim de garantir o direito da pessoa de não produzir prova contra si (deriva das previsões constitucionais – art. 5.º, LVII e LXII – e consagrado do Pacto de São José da Costa Rica, art. 8.º). (...) Além disso, no ponto do consentimento, necessária observância de cuidados, a fim de assegurar que este seja consciente e válido. Frise-se que o consentimento não se presume e requer prova, cujo ônus é do Estado (TRF 2.ª Região, RSE 200551015058355, DJ 22.10.2008). Mais do que isso, parece-nos essencial que sejam esclarecidos, ao sujeito da medida e de forma documentada, os seus direitos, o alcance da inviolabilidade do domicílio e as consequências de sua decisão por franquear a entrada de policiais para a busca domiciliar. Trata-se de medidas mínimas para coibir abusos da autoridade policial e fazer valer um Estado Democrático de Direito” (BOTTINI, Pierpaolo Cruz; DELLOSSO, Ana Fernanda Ayres. O consentimento e a situação de flagrante delito nas buscas domiciliares. Disponível em: . Acesso em 16 jun. 2016) (destaquei).

Não se cuida, aqui, de desmerecer a atividade policial ou de presumir a prática de

qualquer ilegalidade por parte dos policiais. Ao contrário, o que se pondera é justamente que o homem médio brasileiro é profundo desconhecedor de suas garantias mínimas e sente-se coagido diante de tal interpelação policial, com receio do que pode advir de sua negativa. Nesse mesmo sentido, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1690854/RJ: “Por fim, merece destaque a afirmação constante dos autos de que, ao se dirigirem para a residência, os policiais tiveram a entrada franqueada pela proprietária do imóvel (fls. 3 e 256). Tal realidade, a meu ver, demonstra muito mais uma situação aguda, uma vontade externada sob domínio de intensa pressão, do que uma pouco crível colaboração para que, voluntariamente, fosse autorizado o ingresso de agentes policiais em sua residência para a busca domiciliar”. Tampouco houve visualização de situação de flagrante delito no interior da residência que autorizasse a excepcional entrada no domicílio.

Por outro lado, nem se diga que, por se tratarem o tráfico e a posse de drogas de crimes permanentes, havia situação de flagrante delito que justificava o ingresso. A narrativa colhida dos policiais militares deixa claro que, primeiro, houve o ingresso na residência para, depois, ser verificada a situação de flagrante delito, quando só haveria licitude do ingresso no caso contrário, ou seja, se os policiais verificassem que ocorria situação de flagrante delito previamente para só depois ingressarem na residência, amparados pela Constituição Federal, justamente no intuito de fazer cessar a violação à ordem jurídica anteriormente verificada. Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em vários acórdãos: PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL E SEM ELEMENTOS MÍNIMOS DE TRAFICÂNCIA NO LOCAL. PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. Ainda que esta Sexta Turma tenha admitido como fundamento para a prisão preventiva a relevante quantidade entorpecentes apreendidos em poder da paciente, tratando-se de 132 pedras de crack, 84 papелotes de cocaína e ainda 26 trouxinhas de maconha, não foi apontado nenhum elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência da paciente, citando-se apenas a verificação de denúncias de tráfico de drogas que receberam através do “Disque Denúncia”, e a fuga do adolescente. 2. Verifica-se ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, quando não há referência a prévia investigação policial para verificar a possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de informações concretas e robustas acerca da traficância no domicílio violado. 3. Recurso em habeas corpus provido, para a soltura da recorrente, TEREZA RODRIGUES, e de ofício determinar o trancamento da Ação Penal n. 0001783-23.2016.8.26.0695 (STJ, Sexta Turma, RHC 83.501/SP, Rel. Mini. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018) RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). 2. Em nenhum momento, foi explicitado, com dados objetivos do caso, em que consistiria eventual atitude suspeita por parte do acusado, externalizada em atos concretos, tampouco foi feita menção a eventual movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Não há referência a prévia investigação, monitoramento ou campanhas no local. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Há apenas a descrição de que, quando o recorrido avistou os policiais militares, empreendeu fuga. 3. Uma vez que não há nem sequer como inferir, de fatores outros que não a mera fuga ante a iminente abordagem policial,

que o recorrido estivesse praticando delitos de tráfico de drogas, de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não há razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, no domicílio do acusado, de drogas e de arma de fogo de uso restrito, sob pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância. 4. No caso, houve mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo ora recorrido, o que não configurou, por si só, "fundadas razões" a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial. 5. Recurso especial não provido (STJ - REsp: 1690854 RJ 2017/0208328-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

Colhe-se do voto do Ministro Relator neste mesmo julgado:

Para obviar esse tipo de situação, que instabiliza e põe sob permanente risco referida franquia constitucional, não seria desarrazoado sustentar que a hipótese de flagrante delito a que alude o art. 5º, XI, da Constituição da República deveria ao menos em interpretação restritiva compatível para norma que, a rigor, excepciona importantíssima liberdade pública, denotar a situação em que um crime esteja ocorrendo no interior da residência e a urgência não permite aguardar a providência mais segura, cautelosa, a prévia autorização judicial.

Em outro julgado:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NOTÍCIA ANÔNIMA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. APREENSÃO DE DROGAS (87,3G DE MACONHA E 40,1G DE COCAÍNA). AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). 2. Na hipótese vertente, o ingresso forçado na casa onde estava o Réu não possui fundadas razões, pois está apoiado em informação de inteligência policial (notícia anônima) como único elemento prévio à violação do domicílio. 3. Por certo, "embora do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida", a "proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois" (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). 4. Sem embargo, é amplo o leque de elementos que se prestam a preencher o requisito de fundadas razões, pois deve haver compatibilidade com a fase de obtenção de provas. De outra parte, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para caracterizar as fundadas razões. 5. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes, a serem aferidas pela Magistrada sentenciante, devendo o material respectivo ser extraído dos autos, procedendo-se à prolação de nova sentença com base nas provas remanescentes, além de colocar o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso" (HC 496.420/SP, j. 30/05/2019, relatora Ministra Laurita Vaz)

Não se ignora aqui a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015). Tal tese, todavia, deve ser adequadamente analisada e interpretada em cada caso concreto a fim de evitar se converter em salvo-conduto para que o Estado não ingresse em qualquer residência à procura de drogas, em verdadeiras fishing expeditions. É preciso fazer, assim, a devida filtragem constitucional da expressão "fundadas razões", como vem fazendo o Superior Tribunal de Justiça nos julgados acima citados. O voto-vista do Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ no RHC 83501/SP bem esclarece a situação:

Não se desconhece que, consoante afirmou o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do referido RE n. 603.616/RO, 'A busca e apreensão domiciliar é uma medida invasiva, mas de grande valia para a repressão à prática de crimes e para a investigação criminal' (p. 10 do acórdão). Também não perco de vista que, não raro, é tênue a distinção dos limites circunstanciais entre a legitimidade da ação de ingresso e a afetação do direito à inviolabilidade de domicílio. No entanto, é de particular importância (re)pensar em que medida o ingresso na esfera domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa uma intervenção restritiva legítima do ponto de vista constitucional, e não uma violação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio. Isso porque a ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental. Sobre esse cuidado de ocorrerem abusos na invasão de domicílio, Arion Escorsin de Godoy e Domingos Barroso da Costa advertem que: Sabe-se que o flagrante autoriza a violação de domicílio, mas essa relativização do direito fundamental previsto no inc. XI do art. 5º da Constituição não significa abertura a ações policiais que mais se assemelham a apostas lotéricas, em que o prêmio – dependente da sorte do jogador – é o encontro de indícios da prática de tráfico de drogas e a consequente prisão de quem possa ser seu autor. Desconstruindo a afirmativa que deve ser analisada frente às narrativas comuns aos autos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, descobre-se que, em regra, não há uma situação de flagrância comprovadamente constatada antes da invasão de domicílio, o que a torna ilegal, violadora de direito fundamental. Porém, como em um passe de mágica juridicamente insustentável, por uma convalidação judicial, a apreensão de objetos ou substâncias que sejam proibidos ou indicativos da prática de crime e a prisão daquele(s) a quem pertença(m) travestem de legalidade uma ação essencialmente – e originariamente – violadora de direito fundamental. (...) Não se há de admitir, portanto, que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz (um "terceiro neutro e desinteressado") só pode determinar a busca e apreensão durante o dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente (destaquei).

Os elementos que pudessem sugerir possível traficância em relação ao acusado tinham relevância suficiente apenas para discutir o cabimento de um mandado de busca e apreensão, mas não para o ingresso imediato no domicílio pela polícia. Ora, deve-se lembrar que o ingresso em domicílio sem autorização judicial é medida bastante excepcional, justificável apenas quando houver elementos sólidos e concretos da existência de flagrante delito no local naquele momento, e, sobretudo, quando for inviável a solicitação de mandado de busca e apreensão em razão da urgência.

No caso em concreto, a entrada na residência do acusado se justificou na circunstância que haveria denúncias anônimas contra o acusado, sendo que a partir disso os policiais militares desconfiaram que ele pudesse manter droga em depósito em sua residência. Tais elementos são demasiadamente frágeis para se autorizar a presunção de situação de flagrante delito na residência do acusado a autorizar o ingresso.

Em relação à denúncia anônima, sabe-se que, em regra, denúncias anônimas não são suficientes para imediatamente justificar medidas invasivas, mas tão somente para dar início a diligências preliminares de averiguação, tais como campanas, por exemplo. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente decide que "denúncia anônima não é fonte probatória, mas mera informação, passível de gerar movimentação investigatória preliminar, mas jamais fundamento para a restrição a direitos individuais" (RHC n. 53134/RJ. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe: 26/05/2015).

Tratando especificamente sobre a justa causa para ingresso em domicílio a partir de denúncias anônimas, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de ‘informantes policiais’ (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa” (Plenário. RE 603616/R0, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015).

É o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA OBTIDA E DAQUELAS DELA DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protraí-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito. 2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida. 3. A prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados. 4. Recurso especial provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e dela derivadas, por conseguinte, absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP. (REsp 1871856/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) (destacou-se). (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui jurisprudência no sentido de que “A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si só, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial” (RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020) (destacou-se).

Isto não significa desprezar a importância de denúncias anônimas ou ignorar o fato de que muitas vezes são feitas de forma anônima justamente pelo temor que o(a) denunciante tem de ser identificado perante os potenciais criminosos denunciados. No entanto, além da privação do acusado de exercer o direito ao confronto, não se pode desconsiderar que o anonimato isenta o denunciante de qualquer responsabilidade caso empenhe declaração falsa, diferentemente de testemunha identificada, sujeita às penas do crime de falso testemunho. Infelizmente, a prática revela que denúncias anônimas podem ser, por variados motivos, desde trotes de adolescentes até pessoas mal-intencionadas com o único objetivo de causar constrangimento a inocentes com quem tenham alguma inimizade. Estatísticas oficiais mostram que entre 15% a 20% das ligações recebidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo via 190 são trotes, o que equivale a aproximadamente 5.000 chamadas por dia (informação retirada de notícia jornalística disponível em).

Importante notar que inexistia situação de urgência que inviabilizasse a solicitação de mandado de busca e apreensão, de modo que não havia risco na demora de se aguardar o competente mandado, caso deferido.

Todas as hipóteses descritas no art.5º, inciso XI, da Constituição da República, para ingresso na residência à revelia de consentimento do morador, a qualquer hora do dia ou da noite, estão representadas por um contexto emergencial, baseado na ideia de que seria impossível esperar por um mandado judicial. Basta lembrar que as outras hipóteses são o desastre e o socorro imediato.

Por idênticas razões, a regra será, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o ingresso em domicílio alheio sem consentimento durante o dia com ordem judicial, mesmo nos casos de flagrante delito, salvo nos casos em que existam fundadas razões para a atuação imediata a fim de evitar um mal maior. São as hipóteses em que há risco à vida, à integridade física, risco de desaparecimento de corpo de delito, entre outros. Por outro lado, se o crime permanente e a respectiva situação de

flagrante permanente não demandam urgência e admitem que se aguarde por uma ordem judicial, esta deve ser buscada em atenção ao devido processo legal e à garantia da inviolabilidade do domicílio.

É o que há muitos anos já sustentava a lição clássica de CELSO DELMANTO:

Seriam hipóteses, por exemplo, de flagrante de crimes permanentes como a extorsão mediante sequestro, em que há a necessidade de prestar-se socorro imediato à vítima que corre perigo de vida etc., o que não se verifica em casos de crimes permanentes como a simples posse de entorpecentes ou de armas ilegais. (...) Não obstante se possa alegar que esse entendimento poderia obstaculizar a ação policial, este é o preço que se paga por viver em um Estado Democrático de Direito, que deve tomar todas as medidas para restringir, ao máximo, a possibilidade de arbítrios e desmandos das autoridades policiais por mais bem intencionadas que possam elas estar. (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 6. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 324, destaquei).

Em regra, nos crimes de tráfico de drogas não há urgência que impeça o pedido judicial de busca e apreensão, notadamente porque são crimes de perigo abstrato, ou seja, não há dano nem perigo concreto e imediato de dano a bem jurídico. Tal entendimento é reforçado pela própria circunstância que a Lei n. 11343/06 prevê a possibilidade de retardamento da ação policial na figura do “flagrante diferido”, o qual, aliás, somente pode ser realizado com a devida autorização judicial prévia, na linha do que observou o Superior Tribunal de Justiça no HC n. 598051/SP.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação – e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio – justificam o retardo da cessação da prática delitiva.

(...)

[O] tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. (HC 616.584/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021)

Portanto, pelo contexto fático delineado nos autos, não havia elementos concretos que justificassem a invasão de domicílio sem a prévia autorização judicial, valendo destacar, ademais, que não havia urgência que impossibilitasse a solicitação de prévia autorização judicial.

Eis a razão pela qual, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do réu, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas. Além disso, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, “são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”. O dispositivo de lei consagra a teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree ou tainted fruit), desenvolvida pela Suprema Corte Norte-Americana, entre as décadas de 1920 e 1930, especialmente no caso *Silverthorne Lumber & Co. v. United States*, de 1920, e caso *Nardone v. United States*, de 1937, que já era adotada pela doutrina nacional e pelo Supremo Tribunal Federal antes da reforma legal. A prova ilícita por derivação é a prova que, conquanto isoladamente considerada possa ser tida como lícita, ela decorre de informações provenientes de prova ilícita. A prova ilícita por derivação sustenta um argumento relacional, ou seja, para se considerar uma determinada prova como

fruto de uma árvore envenenada, deve-se estabelecer uma conexão entre ambos os extremos da cadeia lógica; dessa forma, deve-se esclarecer quando a primeira ilegalidade é condição sine qua non e motor da obtenção posterior das provas derivadas, que não teriam sido obtidas não fosse a existência da referida ilegalidade originária. Estabelecida a relação, pronuncia-se a ilegalidade. Assim, sendo, são também nulas as provas que derivaram deste primeiro ato de apreensão, resultando no esvaziamento probatório dos autos, a resultar na ausência da materialidade do delito.

Neste contexto, só se pode lamentar que, havendo indícios suficientes para deflagrar uma investigação com a finalidade de interromper a circulação de drogas na região e prender agente da mercancia ilícita, a punição dos culpados seja colocada em risco pela inobservância do devido processo legal. Tais restrições ao desempenho da atividade persecutória – concorde-se ou não; constituam ou não empecilho para a rápida repressão de atividades ilícitas – são constitucionalmente asseguradas, de modo que a sua observância é obrigatória.

Não desconheço que aos olhos de um leigo soe desarrazoado permitir-se a absolvição de um indivíduo "materialmente culpado" pelo fato de a prova contra ele ter sido produzida por meios ilícitos, porque, para o senso comum, os fins justificam os meios. Ocorre que a atividade estatal se encontra balizada por regras de atuação claras e previamente estabelecidas, as quais devem ser rigidamente obedecidas, já que não se está mais no campo da discricionariedade.

Nesse ponto, salutar rememorar as palavras proferidas pelo Ministro NEFI CORDEIRO por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 509030/RJ: "Juiz não enfrenta crimes, juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação. O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e Constituição, com imparcialidade e, somente ao final do processo, sopesando adequadamente as provas, reconhecer a culpa ou declarar a absolvição. Juiz não é símbolo de combate à criminalidade, é definidor da culpa provada, sem receios de criminosos, sem admitir pressões por punições imediata".

Assim, por não remanescerem provas lícitas a respeito da conduta do acusado, de rigor a sua absolvição.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado ANDREY LUIZ CASSIANO da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.).

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Oportunamente, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Viradouro, 10 de agosto de 2022.

PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA